

0001520-91.2016.8.26.0306
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Natália Berti
Comarca: José Bonifácio
Foro: Foro de José Bonifácio
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 17/03/2022
...

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo orientação desta Corte, "[a]s condenações transitadas em julgado pelo crime do art. 28 da Lei n. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de José Bonifácio
Foro de José Bonifácio
2ª Vara
Av. Monsenhor, 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001520-91.2016.8.26.0306 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0001520-91.2016.8.26.0306
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 128/2016 - Delegacia de Polícia de José Bonifácio
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOHN CRISTOPHER DA SILVA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Berti

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou JOÃO VITOR DE SOUZA como incurso nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal; e JOHN CRISTOPHER DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. Consta da denúncia que:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 24 de abril de 2016, por volta das 03h30min, Rua Santos Dumont, Bairro Jardim São José, nesta cidade e Comarca de José Bonifácio, JOÃO VITOR DE SOUZA, com dados de qualificação às fls. 133, em concurso de pessoas e unidades de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça às pessoas Ederson Paulino da Silva e Carlos Alberto Guerreiro Filho, coisas alheias móveis consistentes na motocicleta

Honda/CG 125 Fan, placas DVY1377, de Mendonça/SP, um capacete na cor preto, um relógio e o celular, com chip nº 17- 991610713, pertencentes à vítima Ederson Paulino da Silva.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 24 e 26 de abril de 2016, em horário incerto, nesta cidade e comarca de José Bonifácio, JOHN CRISTOPHER DA SILVA, qualificado às fls. 83, recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente motocicleta Honda/CG 125 Fan, placas DVY1377, de Mendonça/SP, pertencente à vítima Ederson Paulino da Silva.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado João Vitor, juntamente com um indivíduo não identificado, abordou a vítima Ederson Paulino da Silva, que estava conduzindo a sua motocicleta Honda/CG 125 Fan, placas DVY1377, de Mendonça/SP, tendo a vítima Carlos Alberto Guerreiro Filho como passageiro, anunciou assalto, mediante forte ameaça agressão física, e subtraiu a motocicleta e os valores e objeto acima mencionados, evadindo-se em seguida.

Posteriormente, o denunciado John recebeu dos autores do roubo a motocicleta acima descrita pelo valor aproximado de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Na sequência, no dia 26 de abril de 2016, policiais militares abordaram o denunciado John na condução de referida motocicleta.

Auto de reconhecimento fotográfico do denunciado João Vitor pela vítima às fls.10.

Auto de exibição e apreensão às fls. 09; auto de depósito às fls. 11.

A denúncia foi recebida em 28/06/2019 (fls. 198).

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 245/247 e 253/256).

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 262/263) e designada audiência de instrução e julgamento.

Foi realizada audiência de instrução, ouvida a vítima, as testemunhas e interrogado o acusado João Vitor de Souza. O acusado John Cristopher da Silva não foi interrogado em juízo, pois teve sua revelia decretada.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação dos réus.

A defesa do réu JOHN CRISTOPHER sustentou a absolvição do acusado, eis que ausente a prova do dolo quanto à ilicitude da origem do bem. Argumentou, ainda, o erro de tipo quanto à ilicitude da origem do bem. Subsidiariamente, pediu a desclassificação do crime para sua modalidade culposa.

A defesa do réu JOÃO VITOR alega que o réu deve ser absolvido por insuficiência de provas.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

O processo encontra-se formalmente em ordem, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não há nulidades ou vícios a serem sanados. Os acusados foram representados por Defensores e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas, pelo que passo à análise do mérito. A pretensão penal punitiva é parcialmente procedente, sendo as provas suficientes tão somente para fundamentar um decreto condenatório quanto ao delito previsto no artigo 183, caput, do Código Penal, imputado ao acusado JOHN CRISTOPHER DA SILVA. Vejamos.

A prova oral produzida em juízo trouxe os seguintes fatos:

A vítima Ederson Paulino da Silva narrou em juízo que foi vítima de roubo. Disse que estava na calçada com um amigo. Duas pessoas os abordaram com um pedaço de madeira. O réu ameaçou os dois e a vítima entregou seus bens. Entregou a motocicleta e o celular. O réu que proferiu a ameaça. Foi à delegacia e reconheceu o réu como autor do roubo via fotografias. Na data de hoje, não é capaz de reconhecer o réu como autor do fato. Disse que sua moto foi encontrada depois, com o chassi riscado. O réu era magro, mais ou menos 1,70m, cabelo curto, moreno. Fez o reconhecimento na delegacia depois de poucos dias, e que, naquela oportunidade, foram mostradas várias fotos. O réu estava com a face descoberta por ocasião do crime.

Em juízo, a testemunha Carlos Alberto Guerreiro Filho contou que, na data do fato,

duas pessoas pediram a chave da moto, de maneira a se tornar evidente que se tratava de um assalto. Não foi à Delegacia posteriormente, somente na data, com Ederson. A pessoa que anunciou o assalto estava sem capacete. Ficou com medo e se recorda que os indivíduos eram jovens. Reconheceu sua assinatura no termo de fls. 32.

O investigador de polícia Silvio Cruz Dourado disse que, após a vítima prestar queixa na delegacia, descreveu as pessoas que teriam praticado o roubo. Disse que, dias depois, encontraram John na posse da motocicleta, com chassi riscado, e disse que teria sido adquirida de Yago, pessoa que também pratica crimes. Yago não foi reconhecido como autor do crime. João Vitor já era conhecido dos meios policiais. John não disse que a motocicleta tinha origem em leilão. Yago não tinha atividade lícita. A vítima disse que o réu era alto.

O policial militar que participou diretamente da ocorrência, Wellington Jeisson Bruno Guilherme, falou em juízo que identificaram John Christopher conduzindo uma motocicleta com chassi riscado e lacre violado. Os policiais fizeram busca e identificaram que era produto de crime. Indagado o condutor, ele disse que teria adquirido a motocicleta por R\$ 400,00.

De forma similar foi o depoimento do policial militar Elieversson Rodrigo Siqueira em juízo. Acrescentou que o réu disse que não tinha documentos do veículo.

Interrogado, o réu JOÃO VITOR disse que tem 31 anos, trabalhava antes de preso. Negou os fatos. Disse que, no dia 24 de abril, estava trabalhando, das 18h às 6h na roça, sendo que chegou em casa 7h da manhã. Disse que possuía registro. O patrão era Devair Alonso. Alegou que havia dois turnos e iam trabalhar em 5 pessoas. Disse que não se recorda do nome dos funcionários a quem se reportava e que mede em torno 1,80m.

O réu JOHN CRISTOPHER teve sua revelia decretada nos termos do art. 367, do CP, foi fora intimado (fls. 329), mas não compareceu à audiência.

I. Do crime de roubo praticado pelo réu João Vítor de Souza (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal)

Em juízo, o réu negou a prática do delito de roubo.

A versão do judicial não pode ser afastada, com absoluta certeza, pelas provas produzidas nos autos.

A vítima, na Delegacia de Polícia, narrou a prática do roubo com detalhes. Declarou que foi abordado por dois homens, que exigiram dinheiro e o ameaçaram de agressão com um capacete. Assim, a vítima Ederson entregou um celular e um relógio de pulso aos furtadores. Em seguida, o réu e seu comparsa se evadiram, utilizando a motocicleta da vítima.

Perante a Autoridade Policial, Ederson reconheceu o acusado João Vitor como um dos autores da prática delitiva. Nesse sentido, é o auto de reconhecimento fotográfico de fl. 22. Destaco que o procedimento ocorreu de forma regular, uma vez que, segundo o auto de reconhecimento, à vítima foram exibidas fotografias de indivíduos com passagens e algumas delas com pessoas com características semelhantes entre si. Destaco que o auto de reconhecimento fotográfico consignou que Ederson afirmou "reconhecer fotograficamente, sem sombra de dúvidas, João Vítor de Souza, como sendo um dos autores do roubo" (fl. 22).

Todavia, o elemento de informação produzido na fase de investigação policial não foi confirmada por nenhuma prova na fase judicial. Isto porque, ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima Ederson informou ser incapaz de realizar o reconhecimento do réu. Tal situação é compreensível, e até mesmo esperada, considerando o grande decurso de tempo transcorrido entre os fatos (24 de abril de 2016) e a data em que a audiência foi realizada (13 de outubro de 2021- fl. 350). Em que pese a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, fato é que este é o único elemento a imputar a autoria do roubo ao réu. Conforme já mencionado, na fase instrutória, não foi produzida qualquer prova mínima quanto à autoria. Isto porque, a vítima Ederson não conseguiu realizar o reconhecimento do réu durante a audiência de instrução. A vítima Carlos, por sua vez, não foi capaz de apontar os autores do roubo, versão já trazida desde a sua oitiva durante o inquérito policial. O policial civil tão somente confirmou o reconhecimento

realizado durante a fase policial, ao passo que os policiais militares nada souberam falar sobre o roubo. Por fim, não foram apresentadas testemunhas presenciais dos fatos.

Portanto, as provas colhidas sobre a égide do contraditório não permitem inferir a responsabilidade penal do réu. A acusação não se desincumbiu de seu ônus de fazer prova robusta a autorizar o decreto condenatório. A suspeita e a dúvida não bastam e, se dúvida houver, esta é valorada em favor do acusado, em razão do princípio do estado de inocência.

Importante destacar que o Código de Processo Penal, em seu artigo 155, caput, prevê o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o magistrado irá analisar o caso e julgá-lo conforme as provas trazidas aos autos, mas terá discricionariedade para a sua valoração, distinguindo-se, portanto, do princípio da convicção íntima e da prova tarifada. Conforme assinala Guilherme de Souza Nucci:

"(...) a persuasão racional é o método misto, também chamado de convencimento racional, livre convencimento motivado, apreciação fundamentada, ou prova fundamentada. Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (artigo 93, inciso IX), significando permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato (NUCCI, 2008, pag. 339).

Entretanto, a segunda parte do artigo 155, caput, CPP, estabelece que a decisão judicial não pode ser fundamentada, em regra, exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ou seja, os elementos probatórios colhidos em sede policial precisam ser confirmados pelas provas produzidas através da dilação probatória realizada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, não houve a comprovação dos fatos na fase judicial. Assim, os depoimentos apresentados são suficientes para gerar uma dúvida fundada, que deve ser resolvida em favor da acusada.

O conjunto probatório não se mostrou apto a embasar uma condenação contra o réu e a aplicação do princípio in dubio pro reo, a justificar uma absolvição, é medida que se impõe. Nesse sentido, são os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Apelação Criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma e fogo. Pedido de absolvição por insuficiência de provas acolhido. Ausência de prova inequívoca da autoria delitiva. Elementos meramente indiciários insuficientes para sustentar édito condenatório. Aplicação do in dubio pro reo. Recurso provido para absolver o apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP. (TJSP; Apelação Criminal 0000940-82.2017.8.26.0514; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itupeva - Vara Única; Data do Julgamento: 12/07/2019; Data de Registro: 12/07/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - 3 Réus - APELADOS ABSOLVIDOS - RECURSO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1524191-35.2020.8.26.0228; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/03/2022; Data de Registro: 16/03/2022)

APELAÇÃO DEFENSIVA - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO AMPARADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETUADO PELA VÍTIMA EM SOLO POLICIAL - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POR RECONHECIMENTO PESSOAL TANTO NA DELEGACIA COMO EM JUÍZO - AFRONTA AO REGRAMENTO APLICÁVEL - ARTIGO 226, II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E PRECEDENTES - ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO QUE NÃO DEMONSTRA, DE MANEIRA ESCORREITA, A AUTORIA DELITIVA - AUSÊNCIA DA CERTEZA INDISPENSÁVEL QUE JUSTIFICA A ABSOLVIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1502566-53.2019.8.26.0268; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de

Itapecerica da Serra - 4ª Vara; Data do Julgamento: 15/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

APELAÇÃO. Roubo simples. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Admissibilidade. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Reconhecimento pessoal do réu que não foi realizado na fase policial ou em juízo. Acusado que não foi preso em flagrante delito. Reconhecimento fotográfico levado a efeito tão somente perante a autoridade policial. Existência de meros indícios de autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Absolvição que se impõe. Apelo provido. (Apelação Criminal nº 0029227-89.2017.8.26.0050, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Leme Garcia, j. 03.11.2021).

Ressalte-se, uma vez mais, que a autoria se mostrou duvidosa, pois a condenação não pode se fundamentar em juízo de probabilidade. Não havendo plena certeza acerca da prática da conduta típica e antijurídica atribuída ao acusado João Vitor, impõe-se a absolvição, como medida acautelatória do bem jurídico vital do homem, isto é, a sua liberdade. Na dúvida, a garantia da liberdade sempre deve prevalecer sobre o poder punitivo estatal.

II. Do crime de receptação praticado pelo réu John Cristopher da Silva (artigo 180, caput, do Código Penal)

A materialidade do crime está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 04/06 e 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de reconhecimento de coisa (fls. 15), auto de depósito (fls. 16), termo de depoimento e declarações (fls. 20/21, 32, 56/57, 58/60, 100, 123), laudo pericial do veículo (fls. 38/39), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria delitiva também foi suficientemente comprovada.

Como já se disse, o réu JOHN CRISTOPHER não foi interrogado em juízo. Em solo policial (fls. 100), negou ter conhecimento de que a motocicleta era produto de crime, mas confessou a compra do bem de Yago, sem nota fiscal e em valor abaixo daquele praticado no mercado, cerca de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). No entanto, apesar da negativa do réu, infere-se do conjunto probatório que o réu comprou o veículo sabendo da origem criminoso, a configurar o tipo penal do artigo 180, caput, CP. Com efeito, diante da sutileza da prova do conhecimento que informa o conceito da receptação e da inafastável carga subjetiva com que se a recebe, é necessário um conjunto de indícios suficientes para firmar convicção de que o réu sabia da procedência do bem que recebeu.

Na receptação dolosa, onde se exige ciência de parte do agente, de que adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa cuja procedência criminoso, bastaria ao réu negar esse conhecimento para ser, sempre e sempre, absolvido. Por isso que a jurisprudência, acertadamente, entende que a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a situação.

E, da soma de todas essas circunstâncias, é por demais evidente a certeza inquestionável de que o réu, conscientemente e de livre vontade, comprou a motocicleta com conhecimento de sua origem criminoso, caracterizando, assim, o dolo direto que tipifica o delito em questão.

Deveras, a motocicleta foi encontrada com o acusado, em abordagem policial, apresentando lacre rompido, pertencente a outra motocicleta, e numeração de chassi e motor totalmente suprimidos. Acrescente-se a isso que o réu adquiriu a motocicleta por apenas R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), sem qualquer documento comprobatório de propriedade (nota fiscal, documento do veículo etc) e sem realizar qualquer procedimento formal para transferência de propriedade. Não convence a afirmação de que acreditava ser veículo proveniente de leilão.

A versão do acusado está totalmente isolada nos autos. Tal situação denota o dolo para verificação da receptação dolosa, a despeito de o réu não confessar saber que o produto é objeto de crime.

Dessa forma, presente o dolo, impossível a desclassificação para a receptação culposa. A defesa do acusado não apresentou quaisquer documentos que comprovassem a

posse anterior lícita do bem. Nesse sentido:

RECEPTAÇÃO DOLOSA. Réu que não justificou a posse de aparelho celular furtado no dia anterior. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva, bem como do dolo, diante das circunstâncias da abordagem. Condenação mantida. Penas mínimas, fixado o regime aberto e substituída a corporal, na forma do artigo 44, do CP. Apelo improvido. (TJSP; Apelação 0000027-69.2018.8.26.0319; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lençóis Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes(...). (grifei) (STJ - HC: 398211 SP 2017/0099369-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017).

Também não se aplica o artigo 180, §5º, CP, o qual dispõe que: "Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155". O artigo 155, §2º estabelece que: "Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa". No caso, a receptação não envolve bem de pequeno valor. Portanto, a aplicação do benefício é indevida.

Verifico que o réu JOHN CRISTOPHER DA SILVA , à época dos fatos, era primário e não ostentava Maus antecedentes (fls. 288/291).

O réu possuía uma condenação anterior, com trânsito em julgado (fl. 288- processo 0000436-09.2015.8.26.0559), pela prática do delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Sobre o tema, quanto à condenação pelo artigo 28 da Lei de drogas (fl. 241), nos termos da decisão proferida em sede liminar pelo Superior Tribunal de Justiça e na linha do mais recente entendimento que prevalece naquela Corte, ao qual me filio, a condenação anterior pelo crime de porte de drogas para consumo não se presta a gerar reincidência:

Consoante o posicionamento firmado pela Suprema Corte, na questão de ordem no RE n. 430.105/RJ, a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, foi apenas despenalizada pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizada, em outras palavras, não houve abolição criminis. Desse modo, tratando-se de conduta que caracteriza ilícito penal, a condenação anterior pelo crime de porte de entorpecente para uso próprio pode configurar, em tese, reincidência. Contudo, as condenações anteriores por contravenções penais não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes anteriores. E, se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista que nem é punível com pena privativa de liberdade. (HC 453.437/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018).

Assentado tal entendimento, a jurisprudência evoluiu para proibir inclusive a valoração de tais condenações penais anteriores como maus antecedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo orientação desta Corte, "[a]s condenações transitadas em julgado pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não podem ser utilizadas para fundamentar os maus antecedentes do sentenciado" (AgRg no AgRg no AREsp 1.605.930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RESp 1909074/MG, Sexta Turma, Min. Laurista Vaz, j. 22/06/2021).

É o teor dos seguintes julgados da Corte Paulista:

Revisão Criminal – Tráfico de Drogas – Pena-base exasperada ante os maus antecedentes do acusado – Circunstância reconhecida em desacordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça – Condenação anterior pelo crime previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas que não gera maus antecedentes ou reincidência – Aplicação retroativa da jurisprudência, à luz dos princípios da igualdade e da retroatividade da norma mais benéfica – Pena ajustada – Pretensão à redução da fração de acréscimo que incidiu na segunda etapa da dosimetria, em razão da circunstância agravante da reincidência – Impossibilidade, ante a inexistência de ilegalidade na proporção adotada – Discricionariedade do julgador no dimensionamento da pena – Precedente do STF – Revisão criminal que não se presta à reanálise de questões amplamente debatidas na sentença e no acórdão condenatório – Revisão criminal parcialmente provida. (TJSP; Revisão Criminal 2223576-72.2021.8.26.0000; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 5º Grupo de Direito Criminal; Foro de Indaiatuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tráfico ilícito de entorpecentes - Insurgência quanto à dosimetria da pena – Condenação anterior pelo delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006 que não gera maus antecedentes – Precedentes – Penas inalteradas - Prequestionamento – Desnecessidade de enumeração dos artigos legais - Embargos declaratórios parcialmente acolhidos. (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 1500790-07.2020.8.26.0228; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 21/07/2021)

Deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois, embora tenha confirmado a aquisição da motocicleta, negou conhecimento da origem ilícita. Assim, não há dúvidas da prática do crime de receptação imputado ao réu John, sendo o caso de condenação.

Passo à aplicação da pena, em observância ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição, e às diretrizes do artigo 68 do Código Penal.

John Cristopher da Silva

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, CP, verifico que o réu não é portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas, porque todas as circunstâncias são normais e esperadas em delitos desta natureza. Fixo a pena-base em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, presentes a atenuante da menoridade relativa à época dos fatos. Ausentes agravantes. Mantenho a pena intermediária no patamar mínimo já fixado (Súmula 231, do STJ).

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Assim, a pena definitiva é fixada em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Para o cumprimento inicial da pena, fixo o regime aberto, nos termos do artigo 33,

§ 2º, c, CP.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Presentes os requisitos do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta, a ser especificada pelo juízo da execução.

Fica prejudicada a análise da suspensão condicional da pena (artigo 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva apresentada na denúncia para:

ABSOLVER acusado JOÃO VITOR DE SOUZA, RG: 46.268.498, CPF: 389.319.298-03, nascido em 05/06/1990, natural de Santo Antonio do Aracangua - SP, filho de BENICIO BENEDITO DE SOUZA e GENY TEODORA DA COSTA SOUZA, das sanções do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

CONDENAR o acusado JOHN CRISTOPHER DA SILVA, RG: 71.495.121, nascido em 08/04/1997, natural de Viradouro - SP, filho de LUCIANO BENEDITO DA SILVA e JAQUELINE DE CASSIA RIBEIRO ALVES, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial ABERTO, e 10 (dez) dias-multa, cujo valor é fixado em 1/30 do salário mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta, a ser especificada pelo juízo da execução.

Condeno o acusado JOHN CRISTOPHER DA SILVA ao pagamento das custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade de justiça que ora defiro.

O réu John poderá recorrer em liberdade, ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pelo réu (artigo 387, IV, CPP), porque tal questão não foi submetida ao crivo do contraditório.

Comunique-se à vítima.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva de recolhimento, se for o caso. Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil e comunique-se ao TRE para fins do disposto no artigo 15, III da Constituição.

Intimem-se, pessoalmente, os réus.

P.I.C.

José Bonifacio, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA